

1501187-15.2020.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Thais Cristina Monteiro Costa Namba

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... de São Paulo:

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a variedade e a quantidade de drogas apreendidas, dentre outros, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de guardas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

1ª Vara Criminal

Rua Jacob Emmerich, 1367, São Vicente-SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501187-15.2020.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501187-15.2020.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2092079/2020 -

DEL.POL.S.VICENTE, 1180/2020 - DEL.POL.S.VICENTE

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ANDRE RICARDO DOS SANTOS SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Thais Cristina Monteiro Costa Namba

Vistos.

ANDRÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso III, c.c. os artigos 14, inciso II, e 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, pois, segundo narra a denúncia, no dia 11 de abril de 2020, por volta das 22:30 horas, na Praça Vinte e Dois de Janeiro, próximo ao numeral 199, no bairro Gonzaguinha, neste município e comarca de São Vicente/SP, em ocasião de calamidade pública, o denunciado, mediante uso de chave falsa, iniciou a execução de subtração, para si, de coisa móvel, pertencente a Marcelo Marcio Martins Souza.

A denúncia foi recebida em 16 de abril de 2020 (fls. 77/78).

O réu foi citado (fls. 101), apresentando resposta à acusação às fls.113.

Laudo pericial (fls. 160/165).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas. A vítima não compareceu à audiência. O réu, embora devidamente citado, não compareceu em juízo para ser ouvido, tendo sido decretada a sua revelia (fls. 170 - link contendo gravação da audiência).

Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 175/177).

A Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, VII do CPC. Em caso de condenação, pugnou pelo afastamento da qualificadora pelo emprego de chave falsa, fixação da pena base pelo mínimo legal, afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, alínea "j", do CP e incidência da causa de diminuição pelo reconhecimento da tentativa. Por fim, pediu fixação de regime prisional inicial aberto, além da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.(fls.182/186)

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente em parte.

Materialidade delitiva restou demonstrada através do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição/apreensão e entrega (fls.06), laudo pericial de fls. 160/165, bem como pela prova oral coligida nos autos.

A autoria, por sua vez, é inconteste e aponta para o acusado.

O réu não foi ouvido, pois, não compareceu em juízo e teve sua revelia decretada.

A vítima também não compareceu para prestar depoimento em audiência.

Ouvida em juízo, a testemunha Luiz Mauro da Silva Pereira, guarda municipal, disse que na data dos fatos estava em patrulhamento pela GCM e foram acionados pela vítima, que afirmava que havia um indivíduo dentro do veículo dele e também que o veículo estava fora do local que havia deixado. Afirmou que o outro GCM despertou o acusado. Afirmou que a vítima checou o veículo e, posteriormente, o acusado foi conduzido à delegacia. Relata que todos os fios elétricos do veículo estavam expostos. Relata que o acusado acordou assustado e nada disse a respeito do ocorrido. Disse que não conhecia o acusado. Afirmou que estava ao lado do GCM que acordou o acusado. Disse que não foi utilizado gás de pimenta ou utilizada força para acordá-lo, no entanto, o acusado tentou fugir e foi imobilizado. Disse que não notou se o acusado estava machucado. (fls. 170 - link contendo gravação da audiência)

Ouvida em juízo, a testemunha José Ricardo de Almeida Rodrigues, guarda municipal afirmou que estavam fazendo patrulhamento próximo à praça 22 de Janeiro e foram acionados pela vítima, que noticiou que seu veículo estava estacionado em local diverso do que havia deixado e parecia que havia uma pessoa dentro dele. Disse que de imediato encontraram o acusado dormindo dentro do carro e, quando acordado, disse que ele confessou que havia tentado fazer uma ligação direta para sair com o veículo, mas sofreu um apagão. Acredita que o acusado estava dormindo ou sob efeito de drogas ou medicamento. Disse que o veículo estava mal estacionado e o painel estava cheio de fios fora do lugar. Disse que o acusado estava com as mãos machucadas e acordou agitado, querendo brigar, chegou a cuspir em um dos guardas e por isso foi imobilizado e algemado. Não se recorda se foi utilizado gás de pimenta. Disse que nunca havia visto o réu. Esclarece que conseguiu abrir a porta do carro e acordar o acusado, que acordou agitado, querendo fugir e falando coisas desconexas.(fls. 170 - link contendo gravação da audiência)

Estas foram, pois, as provas produzidas sob o crivo do contraditório, das quais a autoria da acusada exsurge indubitável.

Do conjunto probatório formado, depreende-se que o réu tentou subtrair, veículo pertencente à vítima Marcelo Márcio Martins Souza, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

A prova baseada no testemunho dos guardas municipais, que prenderam o acusado em flagrante, é robusta. O relato de ambas as testemunhas, sob o crivo do contraditório, coaduna-se com a versão apresentada em solo policial, no sentido de que faziam patrulhamento próximo ao local e foram acionados pela vítima, que alegava ter encontrado seu veículo parado em local diverso da vaga onde o havia

estacionado e que havia uma pessoa dentro do veículo. Ao se deslocarem até o local dos fatos, depararam-se com o réu na posse da res furtiva, dormindo no interior do veículo pertencente à vítima e o acordaram. Disseram que o acusado acordou agitado e que tentou fugir, motivo pelo qual foi imobilizado. Em relação ao estado do veículo, ambos relataram que o bem móvel estava com toda a sua fiação elétrica exposta. Diante dos fatos, deram voz de prisão em flagrante ao acusado e o conduziram à Delegacia de Polícia.

De se ressaltar que como agentes públicos os guardas municipais gozam de fé pública, não sendo lógico que o mesmo Estado que lhes confere o mister de combater a criminalidade não dê credibilidade a seus relatos.

Ademais, não havia qualquer razão para imputação injusta do crime por parte dos guardas civis, que sequer conheciam o acusado.

Nesse sentido, a posição adotada na Oitava Câmara e na Câmara Especial Virtual de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a variedade e a quantidade de drogas apreendidas, dentre outros, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de guardas municipais quando eles são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Recurso não provido." (TJSP; Apelação Criminal 1501425-27.2022.8.26.0548; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cosmópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 11/11/2022; Data de Registro: 11/11/2022) grifei

"APELAÇÃO. Ato PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação Cível nº 1500327-15.2020.8.26.0471 -Voto nº 5 infracional. Tráfico de drogas. Internação. Arguição de nulidade da audiência realizada por videoconferência. Atos processuais executados na forma admitida no ordenamento jurídico pátrio. Audiências virtuais regulamentadas por este Tribunal pelo Comunicado CG 284/2020, à luz do art. 3º, da Resolução CNJ 313/2020 e dos Provimentos CSM 2545/2020, CSM nº 2549/2020 e 2554/2020. Medida imprescindível diante do atual contexto vivenciado de pandemia da COVID-19. Impossibilidade de efetuação de audiência de maneira diversa. Circunstância da qual não decorreria nenhum prejuízo à defesa ou à acusação. Imprescindibilidade de sua cabal comprovação para reconhecimento de nulidade, não podendo esta ser presumida. Princípio 'pas de nullité sans grief.'. Inteligência do art. 563 do CPP. Preliminar afastada. Precedentes. Absolvição ou imposição de medida mais branda. Impossibilidade. Autoria e materialidade demonstradas. Depoimentos idôneos dos guardas municipais envolvidos na apreensão. Meio seguro de prova. Internação. Cabimento. Gravidade da conduta. Condições pessoais desfavoráveis. Histórico infracional. Ausência de respaldo familiar. Necessidade de afastamento do jovem do meio deletério para um adequado acompanhamento. Sentença mantida. Recurso não provido" (Ap. nº. 1008106-60.2020.8.26.0477; rel. Des. Xavier de Aquino; j. 25.05.2021). grifei

Em termos para prosseguimento, verifica-se que a qualificadora do art. 155, §4º, inciso III, do Código Penal não restou caracterizada.

Isso porque o emprego de chave falsa deve incidir quando o agente se utiliza de instrumento falso, com ou sem a forma de chave, para fazer funcionar o mecanismo do veículo, possibilitando ou facilitando a execução do furto. Logo, não se equipara à denominada "ligação direta" atribuída ao autor no caso dos autos.

Note-se que não foi apreendida chave falsa em poder do réu no momento da abordagem, de forma que não está comprovado que se utilizou de objeto material para ter acesso ao interior do veículo.

Além disso, tanto a vítima em solo policial, quanto as testemunhas, em seus depoimentos na fase administrativa e judicial, relataram que, aparentemente, teria havido uma ligação direta para a ignição do veículo, não havendo menção ao uso de chave falsa.

Em arremate, a prova pericial de fls. 160/165 também não menciona o uso de chave falsa, mas apenas "evidências de uma possível tentativa de ligação direta", razão pela qual afasto a qualificadora em questão.

Nesse sentido, a respeito da celeuma no tocante a chave falsa x ligação direta, já se decidiu:

Apelação da Justiça Pública - Condenação por furto simples - Impossibilidade de reconhecimento do furto qualificado pelo emprego de chave falsa - não há previsão legal para qualificar o furto por meio de 'ligação direta' - pena-base mantida no mínimo legal - ausência de condenação definitiva na folha de antecedentes - reincidência específica bem demonstrada - impossibilidade de compensação integral entre a circunstância agravante e a circunstância atenuante da confissão espontânea, em razão da recalcitrância específica - compensação parcial, com acréscimo da pena inferior àquele devido em razão da reincidência específica - adequação da pena - Regime prisional semiaberto que se mostrou adequado, diante da reincidência - decorrido o prazo para eventual oposição de Embargos de Declaração ou Infringentes, expeça-se mandado de prisão - Recurso de apelação parcialmente provido, com determinação. (TJSP; Apelação Criminal 0070433-83.2017.8.26.0050; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/08/2018; Data de Registro: 20/08/2018) grifei

FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. Rompimento de obstáculo e emprego de chave falsa. Autoria e materialidade não impugnadas. Confissão judicial em harmonia com o restante do conjunto probatório. Condenação mantida Qualificadora do rompimento de obstáculo demonstrada tanto pela prova oral, quanto pela perícia realizada no veículo furtado. Destruição do vidro do automóvel que configura referida qualificadora. Precedente do STJ. Hipótese, contudo, de afastamento do emprego de chave falsa, uma vez que o acusado realizou ligação direta no veículo. Precedente desta Corte de Justiça. Dosimetria. Básicas que devem retornar aos patamares mínimos, uma vez que a única condenação anterior do acusado foi utilizada na sentença para configuração da reincidência. Na segunda fase, exclusão do aumento de um sexto, diante do afastamento da qualificadora do artigo 155, § 4º, III, do CP, tendo a reincidência sido compensada com a confissão espontânea. Recidiva que justificou a fixação do regime inicial semiaberto. Apelo parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1513648-07.2019.8.26.0228; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 13ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/03/2020; Data de Registro: 19/03/2020) grifei e sublinhei

Por fim, afigura-se viável o reconhecimento da figura da tentativa no caso em apreço, tendo em vista que o acusado, apesar de haver removido o veículo do local em que este originalmente havia sido estacionado por seu proprietário, não conseguiu subtrair o bem móvel, em face à atuação dos guardas civis municipais, que o surpreenderam e o detiveram em plena ação delituosa.

Diante do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva para o fim de condenar o réu como incurso nas sanções do art. 155, "caput", c.c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nessas condições e partindo do mínimo legal, passo à dosimetria e individualização da pena, com observância do sistema trifásico (art.68 do CP).

Na primeira fase, presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do Código Penal, maus antecedentes ostentados pelo réu, a) processo nº 0019047-87.2011.8.26.0223, da 1ª Vara Criminal do Guarujá, com trânsito em julgado para o réu em 19/06/2012 (fls. 44); b) processo nº 0003719-17.2004.8.26.0562, da 5ª Vara Criminal de Santos, com trânsito em julgado para o réu em 06/07/2006 (fls. 45); c) processo nº 0019552-30.2000.8.26.0590, da 1ª Vara Criminal de São Vicente/SP, com trânsito em julgado para o réu em 16/10/2000 (fls. 46) e processo nº 0025012-

22.2005.8.26.0590, da 3ª Vara Criminal de São Vicente/SP, com trânsito em julgado para o réu em 13/10/2008 (fls. 47), motivo pelo qual aumento a pena base pela metade, passando a constar 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.

Rechaço o reconhecimento da agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, sob pretexto do crime ter sido praticado em ocasião de calamidade pública. Respeitado entendimento diverso, alinho-me à interpretação de que, para a configuração dessa agravante, exige-se a demonstração de que o infrator, de algum modo, prevaleceu-se dessa situação fática para a prática do crime.

E o que se viu foi justamente o contrário. A pandemia da COVID-19 trouxe mais pobreza e desigualdade social, colocando a economia do País em colapso, retirando-se dezenas de milhares de empregos formais do mercado de trabalho em razão do isolamento social, fato esse público e notório, o que motivou as pessoas a se colocarem no mercado informal do labor, respeitando ou não o isolamento social, condição esta última que somente foi agraciada aos mais privilegiados.

Sendo assim, entendo que não há nenhum nexos causal entre o estado de calamidade que vivenciamos em razão da pandemia do COVID-19 e a prática do delito de furto, na perspectiva de facilitação ou preavalecimento da situação desastrosa que a sociedade atravessou, motivo pelo qual fica rechaçado, com a devida vênia, o reconhecimento dessa agravante.

Na terceira fase, não há causas de aumento. Porém, presente a causa de diminuição decorrente da tentativa, pelo que reduzo a pena em 1/3, considerando que o acusado já havia praticado diversos atos executórios, tendo deixado exposta toda fiação elétrica do veículo, realizado ligação direta, conforme comprova o laudo de fls. 160/165 e movimentado o veículo por alguns metros, tendo chegado muito próximo concluir a subtração se não houvesse adormecido no veículo e sido encontrado em seu interior pelo proprietário e guardas municipais, resultando a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Analisando as peculiaridades do caso concreto e com fulcro nos artigos 33 e 59, do Código Penal, notadamente, com relação aos péssimos antecedentes ostentados pelo réu, fixo o regime inicial de pena como o semiaberto.

Diante das particularidades do caso em concreto e, ainda, nos termos do art. 33 e 59, ambos do CP, notadamente, em função da reincidência do réu, fixo o regime inicial de pena como o semiaberto.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além do sursis penal, nos termos do artigo 44, inciso III e artigo 77, caput e inciso II, do Código Penal.

Diante da ausência de elementos para se aferir a situação econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do montante do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a PRETENSÃO PUNITIVA, para o fim de condenar ANDRÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA como incurso nas penas do art. 155 "caput" c.c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03, observado o disposto no art. 12da Lei 1060/50, posto que lhe concedo os benefícios da gratuidade de justiça.

Tendo em conta o regime semiaberto estabelecido, e considerando o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "fixar o regime semiaberto e manter a prisão preventiva do recorrente, negando-lhe o direito de apelar em liberdade, representa a imposição de um regime prisional mais gravoso daquele que foi estabelecido na instância ordinária, caso ele opte por recorrer" (AgRg no RHC nº 142.615/SC; Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca; Quinta Turma; julgado em 06/04/2021, Dje13/04/2021), o acusado poderá recorrer em liberdade.

Oportunamente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Como trânsito em julgado, oficie-se, com as cautelas de estilo e lance-se o nome do

r  u no rol dos culpados.

P.I.

S  o Vicente, 17 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESS  O   MARGEM DIREITA